

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4683/2562

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาง ส.

นาย ร.

โจทก์

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (18) (ที่แก้ไขใหม่), มาตรา 2 วรรคสอง, มาตรา 3, มาตรา 276 (เดิม), มาตรา 278 (ที่แก้ไขใหม่)

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 มาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 8

แม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (18) ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บัญญัติให้การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น เป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา และมาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา 278 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยวรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษ..." ดังนั้น จากบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ยังคง

บัญญัติว่า การกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นยังเป็นการผิดอยู่ มิได้เป็นเรื่องที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง เพียงแต่เปลี่ยนฐานความผิดจากข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดฐานอนาจารโดยล่วงล้ำเท่านั้น ซึ่งตามสภาพทางธรรมชาติในการกระทำความผิดของจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 278 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) เป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าการกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคหนึ่ง (เดิม) การปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา 278 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า แต่โทษตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง (เดิม) ซึ่งใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิดมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท ส่วนโทษตามมาตรา 278 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท เห็นได้ว่ากฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษจำคุกเท่ากัน แต่โทษปรับตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษปรับที่สูงกว่าโทษปรับตามกฎหมายเดิม ต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยในส่วนนี้ จึงต้องลงโทษจำเลยตามกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลย อันเป็นการใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยไม่ว่าในทางใดตาม ป.อ. มาตรา 3

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 276

ระหว่างพิจารณา นาง ส. มารดาของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต และยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าสินไหม

ทดแทนเป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน
กระทำความผิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์รวม

จำเลยให้การปฏิเสธ และให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
276 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ
6 ปี รวม 2 กระทง รวมจำคุก 12 ปี กับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 278 (เดิม), 91 จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 4 ปี ให้จำเลย
ชำระเงิน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17
มิถุนายน 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของ
จำเลยเป็นการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า แม้ผู้เสียหายมีความ
พิการทางสมอง แต่ยังพอสื่อสารได้ ทั้งขณะเกิดเหตุก็ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เสียหายจึงน่าจะเข้าใจพฤติกรรมที่จำเลยกระทำต่อตนได้ การกระทำของจำเลยทั้ง
สองครั้งนั้น ผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่า จำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้

เสียหาย จนผู้เสียหายรู้สึกเจ็บ ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีการใช้นิ้วมือล้วงล้าสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้ว เพราะมิเช่นนั้นแล้วไม่น่าจะทำให้ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศได้ ผู้เสียหายเบิกความว่า เหตุที่ยินยอมให้จำเลยล้วงละเมิดทางเพศและไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกลัวคำขู่ของจำเลย ดังนั้น จำเลยจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังบังคับผู้เสียหาย การที่ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศอาจเกิดจากผู้เสียหายยังไม่เคยผ่านการร่วมประเวณีมาก่อน ประกอบกับจำเลยใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย จึงทำให้ตรวจไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือรอยฉีกขาดที่เยื่อพรหมจารีและอวัยวะเพศภายนอก ส่วนการกระทำครั้งแรกที่ผู้เสียหายมีประจำเดือนนั้น ก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจำเลยจะไม่ใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ส่วนการกระทำครั้งที่สองแม้ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายแต่งกายอย่างไร แต่ไม่ว่าผู้เสียหายจะสวมกระโปรงหรือนุ่งกางเกงก็ตาม หากจำเลยประสงค์จะล้วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแล้ว ย่อมต้องดิ้นรนฉวยโอกาสจนได้เช่นเดียวกันกับการกระทำครั้งแรกก่อน ๆ ในวันดังกล่าวก็ได้ความว่า ผู้เสียหายนั่งถอนผมหางอกให้จำเลยอยู่เป็นระยะเวลาพอสมควร ย่อมอยู่ในวิสัยที่จำเลยจะหาโอกาสได้ไม่ยาก แม้บริเวณที่เกิดเหตุมีนางสาวป. อยู่ด้วย แต่นางสาว ป. ก็ไม่ได้เฝ้าดูเหตุการณ์โดยตลอด นางสาว ป. ยังเบิกความสนับสนุนด้วยว่า ในวันดังกล่าวสังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างจำเลยกับผู้เสียหาย ดังนี้ พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอมาย่อมรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำต่อผู้เสียหายโดยวิธีสอดใส่นิ้วเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่ เห็นว่า แม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับโดยมาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (18) ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล้วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้

อื่น" มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บัญญัติให้การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น เป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา และมาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา 278 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยวรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษ..." ดังนั้น จากบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ยังคงบัญญัติว่า การกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นยังเป็นการผิดอยู่ มิได้เป็นเรื่องที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง เพียงแต่เปลี่ยนฐานความผิดจากข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดฐานอนาจารโดยล่วงล้ำเท่านั้น ซึ่งตามสภาพทางธรรมชาติในการกระทำความผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) เป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง (เดิม) การปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา 278 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า แต่โทษตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง (เดิม) ซึ่งใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิดมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท ส่วนโทษตามมาตรา 278 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท เห็นได้ว่ากฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษจำคุกเท่ากัน แต่โทษปรับตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษปรับที่สูงกว่าโทษปรับตามกฎหมายเดิม ต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยในส่วนนี้ จึงต้องลงโทษจำเลยตามกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะที่กระทำความผิดบังคับแก่

จำเลย อันเป็นการใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยไม่ว่าในทางใดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278
วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) โดยให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
276 วรรคหนึ่ง (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้
ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก
กระทงละ 4 ปี รวม 2 กระทง รวมจำคุก 8 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูชีพ ปิณฑะสิริ-วงศ์พร จิระภาค-ชัยเจริญ ดุษฎีพร)

ศาลอาญา - นางอชิรญา พลภักดี

ศาลอุทธรณ์ - นายวรพจน์ วิไลชนม์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ134/2560

ต้น

หมายเหตุ